

1502655-65.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... da ação em relação ao crime de tráfico de drogas, enquanto a Defesa do réu Jefferson requer a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico e a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502655-65.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502655-65.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON CHARLES CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JEFFERSON CHARLES CARVALHO e RODRIGO ÁRIAS DA SILVA foram denunciados por incursão no caput do art. 33, em concurso material com o art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua João Aranha Neto, 1400 - Vila Correia, nesta cidade de Mauá, os acusados transportavam, para fins de tráfico, 2 tijolos contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 2.375,31 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31-2 e laudo de constatação de fls. 35-8.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, os acusados associaram-se a pessoas não identificadas para o fim de praticar o delito previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação em relação ao crime de tráfico de drogas, enquanto a Defesa do réu Jefferson requer a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico e a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa do réu Rodrigo busca a absolvição.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede em parte.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.04-8), auto de exibição e apreensão (fls. 31-2), laudo de constatação (fls. 35-8), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 178-80) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria do réu Jefferson. Vejamos:

Os réus, em solo policial, permaneceram em silêncio (fls.13 e 22).

Em juízo, o acusado Rodrigo negou os fatos. Disse que o valor que possuía era decorrente da venda de um terreno, que recebia mensalmente o valor de R\$1.000,00. Foi abordado no caminho de sua casa. Alegou conhecer o réu Jefferson, de vista, porque moram na mesma Vila. Disse que os policiais ficaram com o celular, que depois de um tempo tocou, mas não tinha o número de Jefferson gravado em seu telefone. Não sabe dizer se o corréu Jefferson está envolvido no tráfico de drogas, não conversa com ele (mídia digital).

Sob o contraditório, o réu Jefferson afirmou que estava na posse das drogas. Negou a participação do corréu, bem como de ter se referido ao acusado Rodrigo para os policiais. Disse que conhece Rodrigo de vista porque moram na mesma região e negou ter o contato dele em seu celular (mídia digital).

O policial militar Wagner, na fase administrativa (fls.09-10), historiou que: (sic) "na data de 11/11/2021, por volta de 20h30min, encontrava-se em patrulhamento na localidade do Santa Lídia quando, na Rua João Aranha Neto, em frente ao nº 1.400, Mauá/SP, avistou um indivíduo caminhando pela via, com as mãos em sua cintura como se tivesse segurando algo, ocasião em que se aproximou para proceder a abordagem; que no momento em que o autor, que ora sabe chamar Jefferson Charles Carvalho, notou a aproximação dos policiais, empreendeu fuga, ocasião em que foi perseguido e alcançado e, mesmo detido, ainda entrou em luta corporal com os policiais tentando se desvencilhar; que teve que ser usado os meios necessários para contê-lo, algemando-o; que, em busca pessoal, logrou encontrar, em sua cintura, 02 (dois) 'tabletes' grandes de maconha, com peso superior a 01kg cada tablete; que, indagado sobre a procedência dos entorpecentes, Jefferson informou que havia acabado de pegar os entorpecentes com um indivíduo que estava em um Renault/Sandero, cor preta, e deveria levar os entorpecentes para um amigo seu, de nome 'Rodrigo', que o estava aguardando no interior de um veículo Ford/Fiesta, cor branca, em uma rua acima (Rua Peru), próximo ao local da abordagem, ocasião em que iria receber desse a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), sendo certo que Jefferson iria ser remunerado em R\$ 300,00 (trezentos reais) pelo serviço; que neste momento solicitou apoio de uma outra viatura da Polícia Militar (VTR M30037) para tentar localizar o outro autor, tendo comparecido no local o SGT PM MACIEL (RE 126446-0) que imediatamente localizou referido veículo (placa FIM5610) estacionado na rua, estando em seu

interior o nacional que ora sabe chamar Rodrigo Árias da Silva e, em busca pessoal, foi apreendido consigo a quantia de R\$ 1.062,00 (mil e sessenta e dois reais) em espécie; que inclusive, para confirmar a identidade de Rodrigo, o próprio Jefferson se propôs a ligar do seu telefone celular para o número de Rodrigo, sendo certo que imediatamente o telefone celular de Rodrigo, que estava detido pela outra guarnição, tocou; que indagado, Rodrigo Árias da Silva negou que iria adquirir os entorpecentes e disse que o dinheiro apreendido era 'da venda de um terreno'".

No mesmo sentido o depoimento do policial Gabriel (fls.11-2).

Em juízo, o policial Wagner afirmou que com o acusado Jefferson foram encontrados dois tijolos de maconha. O réu Jefferson disse que receberia o valor de R\$300,00 para entregar a droga para o acusado Rodrigo, que estava esperando na Rua Peru em um veículo Fiesta branco. Solicitou apoio da equipe de Forças Táticas, que na referida rua abordou o réu Rodrigo dentro do carro Fiesta, com a quantia de R\$1.062,00. Pediu para Jefferson ligar para Rodrigo, que atendeu o telefone. Disse que o acusado Rodrigo negou que estivesse esperando Jefferson e ele afirmou para a outra equipe que estava esperando um amigo no local. Afirmou só ter participado da abordagem do réu Jefferson. Nada foi apurado acerca da associação criminosa (mídia digital).

Sob o contraditório, o policial Gabriel reiterou a sua versão. Afirmou que o acusado Jefferson estava na posse das drogas. A outra equipe informou que o réu Rodrigo negou estar esperando o corréu Jefferson (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A quantidade de droga encontrada com o réu Jefferson e as demais circunstâncias da apreensão, tal como a forma em que era transportada, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Todavia, em relação ao acusado Rodrigo, verifica-se, após a análise do conjunto probatório, a ausência de elementos aptos a ensejar o decreto condenatório.

Isso porque o réu negou os fatos, sob a justificativa de que o valor apreendido era decorrente da venda de um terreno, bem como o corréu Jefferson negou sua participação. Acresce-se que com Rodrigo nada de ilícito foi encontrado e além disso, os policiais que o abordaram não foram ouvidos. Assim, a prudência recomenda sua absolvição.

No mais, como bem observado pela douta Promotora de Justiça, há que se afastar o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, pois o delito em tela exige para sua configuração a associação, que requer a união estável com a finalidade de praticar crimes. Caracteriza-se a associação pela permanência e estabilidade. Não há nenhum elemento nos autos, colhido sob o crivo do contraditório, que aponte para tais

requisitos.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação do acusado Jefferson pelo tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em razão da vultuosa quantidade de drogas apreendidas -02 tijolos de maconha-, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido). Nesse sentido, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. DIVERSIDADE, EXPRESSIVA QUANTIDADE E LETALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. [...] REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NEGADO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. II - In casu, a pena-base foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na diversidade, expressiva quantidade e reconhecida letalidade de dois dos entorpecentes apreendidos - 1.091,7 gramas de maconha; 68,2 gramas de cocaína e 73,1 gramas de crack (e-STJ, fl. 91) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 557946 / SP , QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 03/03/2020 DJe 09/03/2020 - grifo nosso).

Na segunda fase, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante na posse de 02 tijolos de maconha, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de mera conveniência.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de

Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Todavia, diante das circunstâncias do delito -o réu foi preso em flagrante com significativa quantidade de entorpecentes, revelando exercer função de confiança no tráfico de drogas, e não comprovou o exercício de atividade lícita-, parece-me claro o acentuado envolvimento do réu no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

O afastamento do redutor, após a majoração da pena base, não implica em bis in idem. Nessa linha, posicionou-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no REsp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Ainda sobre o não reconhecimento do tráfico privilegiado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o

Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, as sanções em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a expressiva quantidade, capaz de atingir elevado número de pessoas, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta. A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON CHARLES CARVALHO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 07 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 700 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei 11.343/06, absolvendo-o da imputação de ofensa ao art. 35 da Lei 11.343/06 e ABSOLVER o réu RODRIGO ÁRIAS DA SILVA, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, ambos com espeque no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Defiro ao réu Jefferson o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas, na

forma dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006. Em relação ao valor apreendido, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, o valor ficará disponível para os interessados, comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado o perdimento do valor apreendido em favor do Funad. Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu Jefferson no rol dos culpados. Deferido os benefícios da justiça gratuita aos réus (fls.87 e 139).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA